

1500138-65.2022.8.26.0633

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO WESLEY NASCIMENTO SILVA

Réu Preso

Juiz Substituto: Dr. ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Relatório

Cuida-se de ação penal pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra BRUNO WESLEY NASCIMENTO SILVA imputando-lhe a prática do crime tipificado no artigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

1ª Vara

Avenida São Paulo, 300, Mongaguá (SP) - cep 11730-000

1500138-65.2022.8.26.0633 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500138-65.2022.8.26.0633

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO WESLEY NASCIMENTO SILVA

Réu Preso

Juiz Substituto: Dr. ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Relatório

Cuida-se de ação penal pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra BRUNO WESLEY NASCIMENTO SILVA imputando-lhe a prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e no artigo 147 do Código Penal e 24-A da Lei 11.340/06.

Sustenta a denúncia que, no dia 02 de abril de 2022, no período da manhã, na Avenida dos Mariscos, nº 17, Flórida Mirim, nesta cidade e comarca de Mongaguá, o acusado trazia consigo, para entrega e venda a terceiros, 52 porções de cocaína, com peso total bruto de 0,38 gramas e 21 porções de crack, com peso total bruto de 6,0 gramas, substâncias essas psicotrópicas e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme o auto de exibição/apreensão de fls. 20/21, e auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 23/24.

Consta ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, BRUNO descumpriu decisão judicial que deferiu medida protetiva de urgência nos autos de nº 1500873-

60.2021.8.26.0366, consistente no afastamento, proibição de aproximação e contato com a ofendida Karolaine, da qual foi devidamente cientificado em solo policial (documentos anexos).

Por fim, também consta, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local BRUNO, no âmbito das relações domésticas e familiares, ameaçou por palavras, causar mal injusto e grave à vítima Karolaine.

Narra que, o denunciado é ex-companheiro da vítima, em cujo favor, foram deferidas medidas protetivas de urgência nos autos de nº 1500873-60.2021.8.26.0366, consistentes, entre outras vedações, na de aproximação e contato com a ofendida, sendo cientificado em solo policial no dia 25 de fevereiro de 2022. Ocorre que, na data dos fatos, o denunciado, descumprindo a medida, foi até a residência da vítima. Não satisfeito, proferiu ameaça contra a ex-companheira, dizendo que iria matá-la. Em razão disso a Polícia Militar foi acionada. Chegando ao local, os agentes da lei lograram êxito em abordar o denunciado. Durante a revista, foram encontradas na bolsa transversal que o acusado trazia consigo 52 porções de cocaína e 21 pedras de craque, além da quantia de R\$ 18,45 em espécie. Diante destes fatos o denunciado recebeu ordem de prisão em flagrante, sendo conduzido ao distrito para a lavratura da ocorrência. Assim, as circunstâncias da abordagem, a quantidade de drogas, as atitudes do denunciado, bem como as demais circunstâncias da abordagem indicam que as drogas apreendidas se destinavam ao consumo e venda a terceiros. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 63/65).

O laudo foi acostado a fls. 152/154 e 157/158.

A denúncia foi recebida (fls. 94/96) e o réu foi citado (fls. 166), apresentou resposta à acusação a fls. 103/116.

Em audiência foram colhidas as declarações da ofendida e os depoimentos das testemunhas e realizado o interrogatório, em que o acusado alega que no dia foi chamado por Karolaine para levar alimentos para os filhos, antes tendo passado e comprado drogas para seu consumo, e que passou a noite na casa de Karolaine a seu convite, de manhã tendo brigado com ela. Nega ter ameaçado Karolaine e diz que, embora soubesse da medida protetiva, tinham reatado o relacionamento. A droga era para seu consumo, tendo pago 650 reais, e seu intuito, no momento, era consumi-la até vir a óbito, pois estava em depressão. Em ocasião anterior foi levado à Delegacia em razão de discussão com Karolaine, quando foi formalmente cientificado da medida protetiva.

Em alegações finais, o Ministério Público pugna pelo parcial acolhimento da pretensão acusatória, ressaltando a suficiência probatória quanto aos crimes de drogas, apenas que deva ser desclassificada a conduta para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/06, com aplicação da pena de advertência, e de descumprimento de medida protetiva, em especial a partir do momento em que se recusou a deixar a residência da vítima quando a tanto instado, com regime inicial aberto e suspensão condicional da pena; e pugna, ainda, pela absolvição quanto ao crime de ameaça ante a falta de provas. E a defesa técnica, pela absolvição do acusado, ressaltando a autorização de Karolaine, o seu depoimento em juízo e o vídeo juntado do dia dos fatos, bem assim as condições pessoais do acusado e a injustiça de estar ele encarcerado, pois o único mal que iria causar seria à própria saúde.

Folha de antecedentes e certidão de distribuição estão a fls. 51/52 e fls. 53.

Fundamentação

Crime do artigo 147 do Código Penal

Diante da manifestação do Ministério Público, titular da ação penal, pugnando pela absolvição do acusado, não há como acolher a pretensão acusatória inicialmente apresentada.

Segundo se entende, o sistema processual penal brasileiro tende ao modelo acusatório, conforme opção inequívoca da Constituição Federal e corolário do Estado Democrático de Direito, da estrutura e organização do Poder Judiciário e do Ministério Público e, sobretudo, da imparcialidade do juiz. Diante da manifestação do titular da ação penal, após o esgotamento da fase instrutória, impõe-se a absolvição quanto a esta imputação.

Crime do artigo 24-A da Lei 11.340/06

A existência do delito, segundo se entende, não restou demonstrada.

Embora bem ciente o acusado BRUNO da medida protetiva antes deferida e ainda em vigor (autos de nº 1500873-60.2021.8.26.0366), inclusive conforme confessado em seu interrogatório, extrai-se da prova oral produzida que a vítima convidou o acusado para o interior de sua residência e com ele dormiu na noite anterior, só pela manhã se opondo à sua permanência e acionando a polícia militar.

Karolaine disse que é casada com BRUNO há 8 anos, com filhos comuns, e em razão de brigas, inclusive porque ele é usuário de drogas, pediu uma medida protetiva. No dia dos fatos, Bruno ligou e relatou que faltava comida. Ele apareceu em casa e acabou aceitando que ele lá permanecesse. No dia seguinte, porém, pediu que saísse, mas ele se negou, daí ter acionado a polícia. Nega ter sido ameaçada por BRUNO no dia, tendo relatado na Delegacia porque estava muito nervosa, sem entender direito o que ele falou. Não presenciou a apreensão das drogas e só viu quando elas estavam na mão dos policiais. Embora constasse estar na pochete dele, só viu nas mãos dos policiais. Não sabe direito o que BRUNO usava, mas acho que cocaína, maconha, pedra. A despeito do tempo do relacionamento, não sabe direito quais drogas, que vêm sendo usadas somente após a separação. BRUNO auxilia no sustento das crianças, embora tenha parado de fazê-lo por um tempo, em especial pouco tempo antes de ser preso. BRUNO trabalhava, em um posto de gasolina, em um quiosque. Quando preso, BRUNO trabalhava no quiosque. Perguntada sobre a representação que fez na Delegacia, disse que sabe das consequências de mentir, mas que não quer mais prejudicar BRUNO, que é usuário. Quer manter sua família. Reataram o relacionamento e o visita no Centro de Detenção. Embora tenha acontecido o fato, já superaram, mas insiste em que não houve ameaça, que não entendeu exatamente. BRUNO dormiu em sua casa no dia 1º e no dia seguinte pediu ajuda da polícia, porque viu umas coisas no celular que não gostou e acabaram brigando.

O policial Michel Silvério Trindade disse que foi acionado para o atendimento de descumprimento de medida protetiva e no local dos fatos fez contato com a Karolaine. BRUNO informou que estava desde o dia anterior, de noite, na residência. Fizeram busca pessoal e encontraram uma pochete preta contendo drogas, incluindo maconha e cocaína. Não se recorda da quantidade exata de droga, mas superior ao normal de consumo. Lida a quantidade do auto de apreensão, reitera que não se recorda da quantidade exata, mas compatível com aquela quantidade. Havia algum dinheiro na pochete, mas pouco, 30 reais ou menos. Informalmente, BRUNO falou que a droga era para consumo próprio. Disse que já tinha atendido outras 2 vezes ocorrências no local, da mesma solicitante Karolaine, uma delas com condução até a Delegacia, mas então sem a ciência da medida protetiva. Ao chegar na residência - que não possui muros -, BRUNO estava no quintal e atendeu de pronto ao chamado policial. A droga estava na pochete na cintura de BRUNO e, informalmente, disse ser para consumo. BRUNO estava com uma lesão na boca que disse que seria de um celular arremessado em sua direção por Karolaine. Depois de passar pelo pronto socorro, conduziu BRUNO à Delegacia. Karolaine disse que teria havido uma discussão na parte da manhã, mas não se recorda se houve agressão ou ameaça. BRUNO disse que dormiu na residência com ela e que a polícia foi acionada em razão de discussão por ciúmes. A testemunha Christoffer Barbosa Dias dos Santos disse BRUNO trabalha para ele, no quiosque, e que, no dia, o esperava e ficou sabendo que ele foi detido. No grupo de mensagens da empresa, foi surpreendido com uma mensagem de Karolaine dizendo que BRUNO era bem casado e que outras mulheres não deveriam procura-lo. Permanece a vaga de BRUNO na empresa, que será gerente de outra empresa que abriu. Certa vez em que BRUNO chegou atrasado, ele relatou que houve um episódio de ciúmes de Karolaine, que danificou seu veículo. Evitavam entrar em contato fora do horário de trabalho com BRUNO em razão desse ciúmes de Karolaine. Nunca presenciou, mas ouviu comentário de que ele faria uso de drogas. No local de trabalho nunca o presenciou sob efeito de entorpecentes, embora seja muito observador quanto a seus funcionários. Tem um quiosque e uma nova adega e presta serviços para bombeiro com prevenção de incêndio. Gerencia o quiosque e a adega e BRUNO trabalha como ajudante de prevenções e instalação de alarmes etc.

Ora, ainda que não se olvide das peculiaridades próprias da violência doméstica e familiar contra a mulher e da situação de sujeição e de ciclo de violência que não raro se verifica, não há como considerar configurado o delito se a vítima, em favor

de quem aplicada a medida protetiva, comprovadamente instiga, estimula e aceita a aproximação do agressor. E isto comprovado não apenas pelo seu depoimento em juízo mas também pelas imagens de vídeo trazidas pela defesa, tudo a corroborar a veracidade do interrogatório.

Tem-se, em tão contexto, renúncia da vítima à proteção conferida pela Lei 11.340/06, que não pode ser ignorada.

Crime da Lei 11.343/06

A existência e a autoria delitivas restaram parcialmente demonstradas pelas provas pericial, documental e oral produzidas.

As declarações do policial em juízo confirmam a apreensão de substâncias nos termos do auto de apreensão, em que o perito oficial detectou a presença de cocaína.

Tudo o que se soma à confissão judicial do acusado (artigo 197 do Código de Processo Penal).

Contudo, segundo se crê, não há prova suficiente quanto a no sentido de que o destino da droga apreendida não fosse o consumo pessoal, mas a entrega a terceiros, de resto nos exatos termos das alegações finais ofertadas pelo Ministério Público. Nos moldes do artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343/06, "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

No caso, a quantidade de droga apreendida não é de todo incompatível com o que normalmente se destinaria ao consumo próprio de um usuário da droga, e infirma a versão acusatória.

Depois, as circunstância da apreensão nada dizem sobre o destino da droga, porque portado pelo acusado no interior de sua residência, quem, ademais, segundo a prova documental e testemunhal produzida, trabalhava lícitamente naquela semana, em um quiosque.

Em suma, a respeito deste elemento do tipo penal, o titular da ação penal não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, restando dúvida quanto a este aspecto da responsabilidade penal do acusado. Assim, não afastada a presunção de inocência a todos assegurada pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, corolário de um Estado Democrático de Direito, impõe-se o afastamento da pretensão neste particular.

Adequação Típica

Como se disse, o quadro probatório evidenciou que o acusado praticou, de forma consciente e deliberada, a conduta de transportar e trazer consigo droga para consumo pessoal, nos exatos termos do artigo 28 da Lei 11.343/06.

Daí porque, nos termos do artigo 383, caput, do Código de Processo Penal, acolho em parte a pretensão acusatória e atribuo qualificação jurídica diversa à denúncia para reconhecer a prática do crime de porte para consumo pessoal.

Prevista na lei penal, a conduta do acusado também é materialmente típica, pois causa expressiva lesão, ainda que potencial, ao bem jurídico penalmente protegido. Por consequência, a severa intervenção penal não viola o direito constitucional à liberdade, atendido o postulado da proporcionalidade.

Observo que não há incompatibilidade entre o preceito do artigo 28 da Lei 11.343/06 e a Constituição Federal, mesmo que sob o pálio do princípio da alteridade. Não há dúvida de que o direito penal deve observar se nortear pelo princípio da alteridade ou transcendentalidade, mas o que é observado por esta norma penal, que não pune o consumo de drogas, mas o seu porte com destino ao consumo pessoal, assim com potencialidade de circulação, gerando um perigo à saúde pública.

Ilícitude e Culpabilidade

Presente a tipicidade, não há elementos a indicar ou a criar séria dúvida de que a conduta tenha sido praticada em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou em exercício regular de direito, o que excluiria a ilicitude da conduta, de acordo com o artigo 23 do Código Penal.

À época dos fatos, o réu era maior de 18 anos, atendido o critério constitucional de imputabilidade (artigo 228 da Constituição Federal); e era plenamente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse

entendimento, sem que haja elementos a indicar ou a criar séria dúvida de que não tivesse plena saúde mental, estivesse fortuitamente embriagado ou sob o efeito de substância psicoativa ou, ainda, sob dependência de droga (artigos 26 e 28 do Código Penal e do artigo 45 da Lei 11.343/2006).

Por fim, culturalmente inserido na sociedade brasileira, o réu tinha ao menos potencial consciência da ilicitude e não há elementos a indicar ou a criar séria dúvida de que lhe fosse inexigível conduta diversa, por estar sob coação irresistível ou agir em estrita obediência a ordem (artigo 22 do Código Penal).

Dosimetria

Passo à individualização da sanção penal exigida pelo artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, com as particularidades inerentes às penas do artigo 28 da Lei 11.343/06.

O nível de consciência do injusto e o grau de exigibilidade de comportamento diverso (cf. Juarez Cirino dos Santos, Direito Penal – Parte Geral, 5ª ed., 2012, p. 518-519) não destoam da culpabilidade já pressuposta na caracterização do crime. O acusado não ostenta maus antecedentes, inexistindo condenação criminal transitada em julgado a ser valorada nesta fase, conforme exige a presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), nos moldes da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça e da tese com repercussão geral decidida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 591054, Relator(a): Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2014).

Nada de desfavorável se comprovou a respeito da conduta social do acusado, o que, de qualquer modo, só justificaria sanção penal mais gravosa em função da prevenção especial positiva, prejudicada ante o “quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas” no sistema penitenciário brasileiro (STF, ADPF 347 MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015). Não tendo o titular da ação penal, neste ponto, se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, de rigor considerar favorável a conduta social do acusado, em atenção ao in dubio pro reo (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).

Não há elemento probatório seguro a respeito da personalidade do acusado, o que é questão técnica complexa e de, no mínimo, duvidosa convencionalidade (v. Corte Interamericana de Direitos Humanos, Fermín Ramírez vs. Guatemala, julgado em 20/06/2005).

Os motivos e as circunstâncias do crime não destoam do que é acobertado pelo tipo penal e não justificam imposição de sanção mais branda ou mais severa.

As consequências do crime são igualmente neutras, nesta fase, diante da extensão relevante, mas não excessiva, de atingimento ao bem jurídico tutelado.

A natureza e a quantidade da droga não são expressivas a ponto de justificar a elevação da pena.

Por tudo isto, considero favorável a conduta social e neutras as demais circunstâncias.

É de rigor, ainda, a atenuação da pena em razão da confissão (artigo 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal).

Assim, suficiente e adequada a aplicação da pena de advertência sobre os efeitos das drogas.

Via de regra, realmente inviável a detração de que trata o artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, remetendo a questão ao juízo da execução. Com efeito, o preceito incluído pela Lei 12.736/12 confunde os institutos diversos da fixação do regime inicial e da progressão de regime e, deste modo, viola a Constituição Federal, que consagra a individualização da pena e a isonomia (artigo 5º, caput e incisos I e XLVI).

Contudo, excepcionalmente na hipótese vertente, em que a sanção penal ao final aplicada é a de advertência, impõe-se desde logo reconhecer a extinção da punibilidade pelo seu cumprimento por força da detração, diante do tempo de prisão, no regime fechado da preventiva, em razão deste processo.

Contabilizo, por apreciação equitativa, o equivalente a 1 dia de prisão, assim cumprida a pena no mesmo dia do cumprimento do mandado de prisão preventiva.

Efeitos secundários da condenação

Considerando demonstrado apenas a destinação ao consumo pessoal da droga, não há que se falar em perda do produto do crime, liberando-se o dinheiro apreendido em favor do acusado.

Dispositivo

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão acusatória para condenar BRUNO WESLEY NASCIMENTO SILVA à pena de advertência, pela prática do crime do artigo 28, caput, da Lei 11.343/06; e absolvê-lo da imputação da prática dos crimes do artigo 147 do Código Penal e do artigo 24-A da Lei 11.340/06, nos termos do artigo 386, incisos II e III, do Código de Processo Penal, respectivamente.

Em razão da detração, julgo extinta desde logo a punibilidade pelo cumprimento da pena imposta. Expeça-se alvará de soltura clausulado, com urgência.

Custas

Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno o réu ao pagamento das custas processuais (artigo 4º, parágrafo 9º, alínea 'a', da Lei Estadual 11.608/03). A gratuidade é questão a ser apreciada em momento oportuno, pelo juízo da execução, se o caso.

Providências Finais

Intimadas as partes em audiência e diante da preclusão inclusive lógica, declaro desde logo o trânsito em julgado.

Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal; comunique-se ao Instituto de Identificação Civil (artigo 709 do Código de Processo Penal); e atualize-se o histórico das partes no cadastro processual com a respectiva anotação.

Arbitro os honorários advocatícios ao(à) defensor(a) nomeado nos autos nos termos do convênio OAB/DPE. Expeça-se certidão de honorários que ficará disponível no sistema SAJ para impressão.

Extinta a punibilidade respectiva, anote-se e archive-se definitivamente.

Int.

Mongaguá, 19 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA